

1501069-30.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTINA FATIMA DE FRANCA e outro

Data da Audiência:

23/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501069-30.2021.8.26.0269 - Controle 2021/000729

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTINA FATIMA DE FRANCA e outro

Data da Audiência:

23/02/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Cleberson França de Jesus. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Sandro Márcio Silva Santos e José Eduardo Natel Sales arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(^a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvidos nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os agentes penitenciários narraram toda

dinâmica das diligências, desde o momento em que receberam o sedex que era destinado ao acusado, e, aberto em sua presença, foram localizados os entorpecentes sintéticos no interior de embalagens de bolachas. Afirmaram que o acusado era o destinatário dos entorpecentes, sendo certo que com o encontro do material, foi encaminhado à polícia civil para apuração de sua natureza, constatando-se que se tratava de substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica. As palavras dos agentes revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda dinâmica da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga, parte prensada na casa e outra já dividida em porções e em unidades embaladas e prontas para a mercancia clandestina, indica claramente que se destinavam, sim, ao tráfico, deitando por terra a versão fantasiosa do acusado de que teria sido colocado seu nome como destinatário, quando, a bem da verdade, foi a própria mãe que lhe enviou o sedex, fato atestado por exame grafotécnico na etiqueta, em que pese sem provas de que soubesse que se tratava de entorpecentes as cartelas de drogas sintéticas. Noutros termos, as circunstâncias do fato, aliados às máximas de experiências, indicam de forma concludente que as drogas eram destinadas ao acusado, e se visava a ulterior entrega ao consumo de terceiros no interior do estabelecimento prisional. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, atentando-se para sua comprovada reincidência, o que obsta a aplicação do redutor e impõe a fixação de regime inicial fechado para débito da sanção privativa de liberdade. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I. DA NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO RÉU: a) Encomenda que não chegou ao seu destino. Ato preparatório. A denúncia descreve que o réu adquiriu, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 8,69g de K-4 (popularmente conhecida como "maconha sintética") – fls. 42-44. No entanto, as circunstâncias narradas pela denúncia não foram minimamente comprovadas. Ainda que considere crível que o réu tenha "encomendado" a droga apreendida (fato também, que não ficou comprovado e será discutido no tópico seguinte), inexistente nos autos elemento de prova que ratifique a entrega de drogas a terceiros, por parte do réu. Dispõe o Código Civil que "a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos, antes da tradição" (art. 1.267). Assim, eventual encomenda, por parte do réu, para que sua genitora enviasse, pelo correio, o entorpecente até o presídio, não implica em aquisição da droga. Quando muito se poderia dizer que a encomenda se trataria de procedimento preparatório da aquisição, mas sem a tradição da droga ao suposto encomendante não está consumado o negócio jurídico. Por outro lado, o réu não chegou a receber a drogas (mas apenas a assinar o termo de responsabilidade com relação ao conteúdo – que, conforme se demonstrará, desconhecia), não se consumou a comercialização dentro do estabelecimento prisional, como noticiado na denúncia, já que o entorpecente foi apreendido antes da hipotética entrega pretendida. Além disso, nenhuma prova consta dos autos no sentido de que o réu vendesse drogas dentro da penitenciária. Os agentes penitenciários nada mencionaram sobre qualquer ato de comércio por parte do réu ou até mesmo avistado qualquer droga com eles. Nenhuma diligência policial nesse sentido foi realizada. Assim, como o fato descrito pelo Ministério Público na inicial acusatória (aquisição, entrega e venda) não restou minimamente comprovado, necessária a absolvição dos réus das imputações constantes da denúncia, valendo os mesmos argumentos em relação ao delito de associação ao tráfico. b) Ausência de provas de que o réu tivesse ciência do conteúdo da encomenda. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Os agentes penitenciários ouvidos narraram,

apenas, circunstâncias da apreensão do objeto, narrando que logo efetuaram a revista, antes da entrega ao réu. Não fizeram qualquer menção sobre terem visto o réu na posse de drogas ou de já terem visualizado o réu comercializando drogas no presídio. O réu negou que tivesse ciência de que havia entorpecentes no meio das bolachas. Reiterou integralmente o depoimento prestado na própria penitenciária quando ouvido em declarações. Ou seja, não há absolutamente nada que indique a prática delitiva por parte do acusado: não há como afirmar que ele soubesse do conteúdo da encomenda. Não há como imputar o delito ao acusado tão somente pelo fato de alguém ter lhe mandado a encomenda contendo entorpecentes, sendo que não há provas de que ele tivesse ciência da existência droga. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3.

Desclassificação. Subsidiariamente, como a acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade de entorpecentes e como o réu não foi preso entregando ou vendendo algo para terceiros, mas apenas recebendo pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico “para consumo pessoal”. Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presume que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Desta maneira, diante da ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. II. TESES SUBSIDIÁRIAS. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) seja fixado regime inicial semiaberto, mesmo que, frise-se, se trate do crime de tráfico, em conformidade com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 718 e 719) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 440), bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), observando-se, ainda, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP; c) o afastamento da causa de aumento de pena pleiteada, visto que não basta que o delito aconteça no interior do presídio, sendo necessário comprovar que o acusado pretendia efetivar comércio de drogas voltado ao sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso; d) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CLEBERSON FRANÇA DE JESUS, qualificado

nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 27 de agosto de 2020, por volta das 16 h e 15 min, nas proximidades da Penitenciária I, situada à Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, km 63, no Bairro Capão Alto, nesta Cidade e Comarca, adquiriu, para fins de comércio, seis fragmentos de papel cor de laranja escuro, contendo o entorpecente “K4 – (5F-MDMB-PICA – carbonoide sintético), sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Notificado, fls. 57, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 60/61. A denúncia foi recebida, fls. 63/64, e o Réu, citado, fls. 96. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Dra. Defensora insistiu na absolvição, e, de forma subsidiária, na desclassificação. É o relatório. I –

FUNDAMENTO. A pretensão é parcialmente procedente. Nas fls. 05/06 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual constou: dois pedaços da caixa tipo "SEDEX", contendo remetente e destinatário e seis cartelas de uma substância sintética, com peso de 8,59 gramas. O Laudo de Exame Definitivo em Substância Entorpecente, n. 287.649/2020, fls. 18/20, consignou o que segue: "O resultado do exame segue em anexo, podendo ser observado no Relatório de Análise 294.276/2020 de 02/11/2020, enviado pelo setor competente em 06/11/2020". O Relatório de Análise n. 294.276/2020, fls. 21/23, consignou o que segue: "3. RESULTADO: As análises realizadas no material no material acima descrito revelaram resultado POSITIVO para 5F-MDMB-PICA, canabinoide sintético, constante na lista F2 da portaria SVS/MS 344, classificação estrutural b.6 (estrutura 9). Metodologia adotada: CG / MS (cromatografia à gás acoplada ao espectrômetro de massa)". Às fls. 27/35 foi juntado o Exame Grafotécnico n. 46.664/2021, no qual consta: "Conclusão Do acima exposto o Perito conclui que os preenchimentos das "peças de exames", partiram do punho escrevente de Cristina Fátima de França. Tais conclusões fundamentou-se nas convergências gráficas, tanto nos elementos de ordem geral da escrita, como de natureza genética, ao confrontar peça de exame com padrão fornecido". Sandro Márcio Silva Santos, agente penitenciário, disseram que receberam uma correspondência endereçada ao Acusado; fizeram a conferência do remetente, era a mãe do Acusado, e confirmaram o cadastro da mencionada pessoa junto ao sistema da Unidade Prisional; o Acusado confirmou que era sua mãe; abriram a embalagem para conferência e constataram que havia pacotes de bolacha com fragmentos de papel com substância entorpecente. José Eduardo Natel Sales, Testemunha, disse que interceptaram drogas em correspondência endereçada ao Réu e fizeram a condução à Delegacia de Polícia. Cléberson França de Jesus, Réu, ao ser interrogado, disse que a remetente não era sua mãe, apenas usaram o nome dela e do Acusado; não sabia o que tinha no envelope; sua genitora sequer sai de casa. Confrontando-se a prova coligida, verifica-se que a parcial procedência é medida que se impõe, pois os agentes penitenciários descobriram, dentro da embalagem destinada ao Réu, seis fragmentos de papel cor de laranja escuro, contendo o entorpecente "K4 - (5F-MDMB-PICA - carbonóide sintético), que havia sido enviada por sua genitora, conforme laudo acima reproduzido. Não é o caso de absolvição, pois, ainda que a droga não tenha sido entregue ao destinatário, houve o ato de adquirir e o único interessado era o Réu, não sua mãe, que apenas efetuou a remessa dos entorpecentes; nestes termos é óbvio que o Acusado estava ciente de que a correspondência tinha drogas. A tese do Réu de ignorância acerca do conteúdo restou isolada e inverossímil. Todavia, a quantidade apreendida é pequena, compatível com a destinação própria, havia poucas unidades, e não há qualquer outra investigação que aponte o Réu como sendo o autor de tráfico de drogas dentro do presídio. Tratando-se de usuário de entorpecentes, óbvio que as drogas tinham sido por ele adquiridas, notadamente porque a remetente era sua genitora, todavia, em virtude da pequena quantidade e pela dúvida acerca da posterior alienação, a conclusão é que as drogas eram destinadas ao uso pelo Acusado. Em síntese, em virtude de todas essas circunstâncias, não se autoriza a prolação de decreto condenatório por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas e mister é a desclassificação da conduta imputada ao Réu para a tipificada no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. ART. 28, DA LEI 11.343/2006: Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia e o faço para condenar, CLEBERSON FRANÇA DE JESUS, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-o como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo

digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 23 de fevereiro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA